

1501592-32.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501592-32.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501592-32.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2219239/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 19594564 - DEL.POL.ITAPEVI, 2249/21/407 -

DEL.POL.ITAPEVI, 2219239 - DEL.POL.ITAPEVI, 2249/2021 - Delegacia de Polícia de Itapevi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD, registrado civilmente como RICHARD GABRIEL SILVEIRA SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

RICHARD GABRIEL SILVEIRA SOUSA e NICOLAS ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 13h45min, na Rua Ceará Mirim, n.º 44, Jardim Briquet, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa do réu Richard Gabriel Silveira Sousa requereu a instauração de incidente de insanidade mental (f. 113-115), o que, após parecer do Ministério Público (f. 119-120), restou indeferido por este juízo (f. 123-124). Os réus foram notificados (f. 160 e 166) e apresentaram defesa prévia (f. 138-139 e 187-188).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 03 de agosto de 2022 (f. 191-192). Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 249). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais (f. 247-248) e memoriais (f. 250-256 e 259-262).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 14, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como um aparelho de telefone celular e a quantia de R\$ 226,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 214-216), sendo que o resultado foi positivo para “maconha”, droga de uso proscrito no Brasil.

A autoria delitiva também é inconteste.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram os réus empreendendo fuga assim que avistaram a viatura. Perseguiram-nos e os abordaram. Em posse do réu Richard Gabriel Silveira Sousa havia drogas e uma quantia de dinheiro. Durante a fuga, o acusado Nicolas Alves dos Santos dispensou uma sacola dentro de uma residência; retornaram ao local e apreenderam a sacola, sendo que ela continha drogas em seu interior.

O réu Richard Gabriel Silveira Sousa alega em seu interrogatório que o corréu estava dormindo na sua casa e eles saíram para comprar frutas. No caminho, policiais civis disfarçados os renderam e os levaram para sua casa, renderam seu irmão menor de idade, e apareceram com drogas que pegaram no vizinho.

O réu Nicolas Alves dos Santos, por sua vez, afirma que estava com o corréu na frente da casa dele, sentados na calçada, comendo frutas, quando apareceu um carro preto e saiu um policial de dentro dele. O policial os enquadraram, entrou na casa de Richard Gabriel Silveira Sousa e vasculhou o local; após não encontrar nada, chamou seis viaturas que chegaram lá. Os policiais começaram, então, a revistar todas as lajes das casas do local e, no vizinho, encontraram uma sacola grande com drogas, que disseram pertencer aos réus.

Estão isoladas nos autos, contudo, as versões dos acusados de que não estavam traficando drogas.

De fato, não é crível que os policiais tenham armado o flagrante e imputado aos réus a posse de drogas que encontraram na casa vizinha – não há, aliás, qualquer elemento nos autos que comprove a versão dos acusados.

Ademais, os policiais afirmam, em depoimento uníssono, que o que despertou a suspeita em relação aos acusados foi o fato de eles terem empreendido fuga assim que avistaram a viatura de polícia. Perseguiram-nos e, em sua posse e na sacola dispensada durante a fuga, foram encontradas as porções de drogas.

Aliás, em juízo, os réus afirmam não conhecer os policiais militares que realizaram a abordagem, não sabendo indicar por que razão eles os acusariam falsamente.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu Richard Gabriel Silveira Sousa não preenche o primeiro requisito, pois é reincidente específico, de acordo com a certidão de f. 240-242. Outrossim, os acusados estavam na posse de quantidade considerável de entorpecentes (mais de meio quilo de maconha).

Nesses termos, e considerando, ainda, que a prisão em flagrante ocorreu em lugar conhecido como ponto de tráfico e que os acusados já tinham uma quantidade de dinheiro em espécie em seu poder, o que indica já ter ocorrido comercialização das substâncias, conclui-se que os réus possuem certa estrutura para o tráfico, não merecendo, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena em tela.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, traziam consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao

comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado Richard Gabriel Silveira Sousa ostenta uma condenação com trânsito em julgado (f. 240-241), a qual, todavia, será sopesada na segunda fase da dosimetria.

O réu Nicolas Alves dos Santos não ostenta antecedentes criminais que demandem a exasperação da pena nesta fase, conforme enunciado da súmula n.º 444 do STJ.

Por outro lado, importante ressaltar que, em seu interrogatório, o denunciado Richard Gabriel Silveira Sousa afirmou ser usuário de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à sua conduta social, já que, além de traficar drogas, financia indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial preponderante negativa em relação ao acusado Richard Gabriel Silveira Sousa (conduta social), fixo a sua pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão – e 666 dias-multa.

Noutra senda, não havendo circunstâncias negativas atinentes ao réu Nicolas Alves dos Santos, fixo a sua pena-base em 05 anos de reclusão – e 500 dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada em relação a ambos os réus, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que os acusados eram menores de 21 anos de idade na data dos fatos (f. 06 e 08).

Contudo, tendo em vista o enunciado da súmula n.º 231 do STJ, do qual se comunga entendimento, fixo a pena do réu Nicolas Alves dos Santos, provisoriamente, em 05 anos de reclusão – e 500 dias-multa.

Quanto ao réu Richard Gabriel Silveira Sousa, há, também, a agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme certidão de f. 240-242, o acusado cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, I, ambos do CP.

No ponto, ressalto que o acusado é reincidente específico, pois foi condenado anteriormente também por tráfico ilícito de entorpecentes, o que reclama uma exasperação mais severa do que a fração habitualmente utilizada de 1/6.

Assim, ante o concurso de atenuantes e agravantes, nos termos do art. 67 do CP, e considerando a preponderância da reincidência específica, aumento a reprimenda em 1/8, perfazendo 07 anos e 06 meses de reclusão – e 749 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: a) 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa para o réu Richard Gabriel Silveira Sousa; e b) 05 (cinco) anos de reclusão – e 500 (quinhentos) dias-multa para o acusado Nicolas Alves dos Santos.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo aos acusados.

Mantenho a custódia cautelar dos denunciados, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo os réus na prisão onde se encontram. Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para os seguintes efeitos:

- (a) condenar o réu RICHARD GABRIEL SILVEIRA SOUSA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado; e
- (b) condenar o réu NICOLAS ALVES DOS SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão – e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido, para ambos os réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeçam-se as guias de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeçam-se as guias de execução definitivas;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 03 de novembro de 2022.